

1500725-69.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... 23 anos e desconhece se Gabriel concorre no tráfico praticado no local. Disse que o tráfico costuma ocorrer lá em cima no pasto, mas não sabe dizer se o consumidor vai ao encontro do traficante em cima do morro ou se eles compram na rua. Confirma que no pasto há intenso movimento de tráfico. Não tem lembrança de qual dia da semana Gabriel foi preso, mas ratifica que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500725-69.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500725-69.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133042/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 17944654 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1070/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1070/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2133042 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SEIXAS GARCIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

GABRIEL SEIXAS GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 16 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Caçapava, trazia consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 89 (oitenta e nove) porções de Cannabis sativa L. (maconha), 86 (oitenta e seis) porções de cocaína e 71 porções de crack (subproduto da cocaína),

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 100), apresentou defesa prévia (fls. 78/95), sendo recebida a denúncia em 19/08/2021 (fls. 146/148) e o acusado citado pessoalmente (fls. 206).

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 2/4), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 5), Laudo de Constatação Provisória (fls. 23/29), Exame Químico-Toxicológico (fls. 71/73) e pela prova oral coligida.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, GABRIEL SEIXAS GARCIA negou a autoria dos fatos. Disse que a única droga que foi apreendida em seu poder foi uma bucha de maconha.

Ponderou que estava em cima do morro quando os policiais viraram a rua; nesse momento, os dois moleques saíram correndo para cima e o interrogando para baixo, escondendo-se até a polícia sair. No entanto, passados uns vinte minutos, enquanto descia para a casa de Erick, perto do mato, os policiais vieram armados com a sacola na mão dizendo que era para o interrogando assumir. No entanto, não havia razão para os policiais atribuírem a droga a sua pessoa, esclarecendo que o entorpecente foi forjado pela polícia, mas desconhece o motivo. Reafirmou que estava apenas com uma bucha de maconha para uso próprio, que foi agredido pelos policiais com tapa na cara e chutes na perna. Foi somente para sair daquele momento de opressão e violência policial que acabou assumindo a propriedade das drogas, afirmando que a adquirira de um traficante de nome David, de São José. Após isso, gritou por socorro. Os policiais militares disseram que era para dizer que não foi agredido ou ameaçado, por isso, na delegacia, confirmou que a droga era sua. Havia dois policiais no mato e outros na rua atrás da Rua Darcy Mota. Estava sem dinheiro no momento de sua prisão, pois o único dinheiro que possuía gastou comprando a bucha de maconha. O policial militar ficou encarando o interrogando na delegacia, razão pela qual assumiu tudo no interrogatório. Pediu socorro, pois estava há uns trinta metros da casa da senhora Célia. Reafirma que nunca traficou e que nunca teve qualquer relação com os traficantes do local. Na hora que estava descendo o morro, os policiais apontaram a arma e exigiram que o interrogando deitasse no chão; eles estavam com a droga nas mãos e começaram as agressões.

A versão do acusado é isolada no contexto probatório.

Com efeito, o policial militar THIAGO ROBERTO LONGHI, sob o crivo do contraditório, confirmou que, na data dos fatos, estavam diligenciando em local conhecido pelo tráfico de drogas e, durante incursão pela mata, o declarante e o parceiro visualizaram o réu com uma sacola nas mãos. Durante buscas na sacola encontraram as substâncias entorpecentes apreendidas, a saber, 89 invólucros de maconha, 86 ependorfs de cocaína, 71 pedras de crack, além de R\$63,00 em dinheiro. O réu admitiu o tráfico, alegando que passava por dificuldades financeiras e que pegava o entorpecente de um indivíduo de nome David, de São José dos Campos. Adentraram pela área de mata andando pelo morro. O réu foi abordado na região de mato do morro, próximo de uma árvore. Ao notar a presença da polícia, o réu soltou a sacola e admitiu, de pronto, a prática do tráfico. O réu estava sozinho no local. Não havia denúncias contra o réu e o local é utilizado por vários traficantes. Somente na sacola que o réu carregava havia drogas, pois nada de ilícito foi encontrado durante busca pessoal. Foi seu parceiro de farda quem fez a busca no réu. Depois chegou outra equipe para dar apoio à diligência policial. Não se recorda se o réu estava de pé ou deitado por ocasião de sua abordagem. Não conhecia o acusado anteriormente.

A corroborar, o agente militar MARCELO MACIEL DA SILVA, em juízo, asseverou que, na data dos fatos, fez abordagem no acusado, mandando-o deitar no chão. Em poder do

acusado, isto é, em suas vestes e no corpo, nada foi encontrado de ilícito. O dia era frio e estava nublado. Adentraram no campo pela Rua Darcy Mota. Todavia, ao adentrarem na mata, local ponto de tráfico, o réu veio em sua direção imaginando que fossem compradores com uma sacola na mão. Foi na hora que mandaram o réu colocar a mão na cabeça e se deitar, ele largou a sacola. O acusado se aproximou do declarante, a uma distância de no máximo dois metros, sem reconhecê-los como polícia; estavam há uns 150 metros da rua. Deixaram a viatura estacionada na rua paralela. Eram duas viaturas, mas quem foi ao mato foi o declarante e o sargento Longhi. Todas as drogas estavam na mesma sacola. Não conhecia o réu e nunca o abordou anteriormente. O réu admitiu a prática do tráfico, esclarecendo que adquiriu o entorpecente de um traficante chamado David, de São José dos Campos. A testemunha CELIA MARIA APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA afirmou que conhece Gabriel, mas desconhece se ele é envolvido com o tráfico. Conhece Gabriel, pois ele é amigo de Erick, morador da rua. Disse que, no dia, foi abrir a janela e viu uma pessoa gritando por socorro; não se recorda quanto tempo isso demorou e não viu se Gabriel foi agredido pelos policiais. Mora no local há 23 anos e desconhece se Gabriel concorre no tráfico praticado no local. Disse que o tráfico costuma ocorrer lá em cima no pasto, mas não sabe dizer se o consumidor vai ao encontro do traficante em cima do morro ou se eles compram na rua. Confirma que no pasto há intenso movimento de tráfico. Não tem lembrança de qual dia da semana Gabriel foi preso, mas ratifica que abriu a janela e viu alguém gritando, porém, não presenciou a abordagem. O informante da defesa ERICK FELIPE ROQUE FARIA, em juízo, disse que tem conhecimento de que há tráfico no local dos fatos, mas desconhece se Gabriel traficava. Gabriel costumava ficar no lugar conversando ou fumando com o depoente. O depoente estava com Gabriel no dia dos fatos; estava em casa e Gabriel o chamou para fumar maconha. Após isso, Gabriel saiu para buscar a droga enquanto o declarante foi ao banheiro; todavia, ao sair de casa, Gabriel já havia sido preso e estava descendo a rua com os policiais. Normalmente, as pessoas têm que ir até em cima do morro para buscar drogas com os traficantes. Normalmente ficam uns três moleques vendendo drogas lá em cima, mas toda horam mudam os vendedores. Não viu o momento da abordagem em Gabriel, pois o depoente estava em casa no banheiro. Gabriel disse que ia subir o morro para buscar drogas dos moleques. O declarante teve passagem por tráfico.

CAMILA RAMOS LOBATO, companheira do réu, disse que está há seis anos com Gabriel, com quem tem uma filha. Desconhece se Gabriel trafica, mas é de seu conhecimento que ele é usuário de maconha. Na data dos fatos, Gabriel disse que iria na casa de Erick pegar uma bucha para fumar; no entanto, passado algum tempo, sua vizinha chegou e disse que estava cheio de polícia na rua. Nesse momento, a declarante não imaginou que Gabriel tivesse sido preso, vindo a saber do ocorrido apenas após a polícia invadir sua residência. Teve contato com Gabriel e pode perceber que ele estava sujo e molhado quando de sua prisão. A roupa de Gabriel foi devolvida três meses depois.

Pois bem!

Em que pese o esforço da combativa Defesa, não há nenhum indício de insinceridade nas palavras dos policiais militares THIAGO ROBERTO LONGHI e MARCELO MACIEL DA SILVA, tampouco elementos que indiquem que o flagrante em questão foi forjado. Com efeito, GABRIEL insinuou em seu interrogatório judicial que confessou em solo policial a prática do tráfico de drogas, inclusive ter adquirido a droga de um traficante chamado David de São José dos Campos, pois foi oprimido e agredido fisicamente pelos policiais militares que efetuarão sua prisão em flagrante. No entanto, diversa e curiosamente, pelo que se observa de seu interrogatório extrajudicial, GABRIEL silenciou-se em solo policial, manifestando o desejo de se pronunciar apenas sob o crivo do contraditório. Ademais, ao ser interrogado perante o delegado de polícia (fls. 07), GABRIEL foi enfático em dizer que “não foi agredido ou ameaçado por qualquer dos envolvidos” em sua prisão.

A narrativa de GABRIEL em juízo, além de contraditória, pois não houve confissão extrajudicial, foi desmentida veementemente pelos policiais militares THIAGO ROBERTO LONGHI e MARCELO MACIEL DA SILVA, segundo quem o réu de pronto admitiu informalmente a prática do tráfico, a indicar seu espírito colaborativo com o

desfecho da ocorrência, a despeito de seu silêncio em solo policial. Ainda que assim não fosse, não há razões para se duvidar da lisura da ação policial, contra a qual não foi comprovada qualquer causa de suspeição ou inidoneidade, não sendo crível que agentes estatais forjariam evidências em desfavor do acusado, pessoa que sequer conheciam. Afora isso, nenhuma das testemunhas arroladas pela Defesa presenciou o momento exato da abordagem policial no réu na mata, pelo que prevalece a narrativa dos agentes estatais.

Nem mesmo a testemunha CÉLIA MARIA, moradora da vizinhança, soube precisar se a alegada pessoa que pedia por socorro era GABRIEL.

As demais testemunhas arroladas pela Defesa, pessoas próximas e do convívio estreito do réu, além de suspeitas, pois são sua esposa e amigo íntimo, nada esclareceram de relevante à elucidação dos fatos, apenas atestaram que GABRIEL é usuário de maconha.

Todavia, eventual condição de usuário do acusado não afasta, por si só, a de traficante, já que é de sabença geral que muitos usuários se envolvem com o tráfico à vista da necessidade de sustentar o próprio vício, recebendo porções de droga como pagamento pela mercancia ilícita praticada.

A finalidade da traficância, por fim, restou devidamente demonstrada.

Como se sabe, o tráfico de entorpecente trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"); a Lei Especial não exige que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 615.337/PR – 5ª T. – Rel. Min. Gurgel de Faria – j. 30.06.2015 – DJe 04.08.2015; HC 306.117/SP – 5ª T. – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 16.04.2015 – DJe 29.04.2015 e HC 217.665/SP – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – j. 05.02.2015 – DJe 20.02.2015).

Bem por isso, a conduta punível não é apenas vender ou expor à venda, mas, igualmente, trazer consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que ficou evidenciado nos autos.

É dizer: mesmo não tendo os policiais presenciado ato de mercancia de entorpecente pelo réu, tal fato não enseja o afastamento da prática da conduta típica que lhe foi imputada, pois a simples ação de trazer consigo os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiro, é suficiente para a caracterização do delito.

Outrossim, as circunstâncias da prisão, o encontro de variadas drogas embaladas individualmente prontas para o comércio e dinheiro, além da confissão informal do denunciado revelam que GABRIEL estava envolvido com o tráfico e que os entorpecentes apreendidos se destinavam exclusivamente ao tráfico ilícito de drogas.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Nesse cenário, comprovadas a materialidade e autoria do delito, de rigor, pois, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, diante da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, a saber, em 89 (oitenta e nove) porções de Cannabis sativa L. (maconha), 86 (oitenta e seis) porções de cocaína e 71 porções de crack (subproduto da cocaína), as duas últimas sabidamente de alto poder nocivo, aumento a pena-base em 1/6, perfazendo o total provisório de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de

reclusão, além 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Anote-se que, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes atenuantes. Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, não se podendo negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade. Desse modo, realizo o acréscimo de 1/6, o que enseja o total provisório de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.

Todavia, o réu faz jus à diminuição de metade das penas com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que resulta no total de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, além de 340 dias-multa, pois, além de primário e sem antecedentes criminais, não há provas de que integre organização criminosa. No entanto, a apreensão em poder do réu de considerável e variada quantidade de drogas, em local conhecido como ponto de mercancia, além de dinheiro afastam a possibilidade da redução máxima da pena em virtude do privilégio, pois denota um envolvimento maior do réu com o crime, situação incompatível com a de um novato.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o tempo de prisão preventiva (oito meses - artigo 387, §2º, CPP), as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, sua primariedade e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, adotando regime mais brando, em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: "A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011". HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente

ação penal e, em consequência, CONDENO GABRIEL SEIXAS GARCIA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 ao cumprimento da pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 340 dias-multa, no menor valor unitário.

Substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaíndo, preferencialmente, em favor daquelas voltadas à reabilitação de dependentes químicos.

Tendo em vista o período em que o acusado se encontra preso preventivamente (8 meses), o regime de pena aplicado (aberto) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, REVOGO a prisão preventiva, CONCEDENDO-LHE o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Declaro a perda do numerário apreendido em favor da União, nos termos da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA